

1. 判决书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02刑终306号刑事判决书

2. 案由：非法吸收公众存款罪

【基本案情】

被告人钱某某、杨某某、金某某、杜某某、李某于2012年至2019年3月，伙同刘某东等人(另案处理)，以投资公司等公司、企业名义，在未经有关部门依法批准的情况下，通过媒体、客户见面会、电话、传单等途径向社会公开宣传，与投资人签订《债权转让及受让协议》等协议，以约定债权转让、线上理财等形式，承诺在一定期限内还本并支付高额回报，向社会公众吸收资金。经审计，钱某某参与非法吸收资金共计500余亿元，违法所得460余万元；杨某某参与非法吸收资金共计200余亿元，违法所得250余万元；金某某参与非法吸收资金共计300余亿元，违法所得90余万元；杜某某参与非法吸收资金共计500余亿元，违法所得100余万元；李某参与非法吸收资金共计900余亿元，违法所得50余万元。钱某某、杨某某、金某某分别于2020年10月9日、10月2日、10月8日被民警抓获到案；杜某某于2020年10月3日经民警电话传唤到案；李某于2020年10月9日到公安机关投案。案发后，钱某某已退赔920万元，杨某某已退赔504万元，金某某已退赔285万元，杜某某已退赔205万元，李某已退赔78.33万元。上述钱款部分扣押于侦查机关，部分扣押于北京市东城区人民法院。

【案件焦点】

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行之前实施的非法吸收公众存款犯罪，法院是否需适用《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条关于罚金刑的规定。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：被告人钱某某、杨某某、金某某、杜某某、李某违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于被告人钱某某、杨某某、金某某、杜某某、李某均能自愿认罪认罚、积极退赔赃款，且杜某某有自首情节，分别对钱某某、杨某某、金某某、李某从宽处罚，对杜某某减轻处罚。故，判决：

一、被告人钱某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；

二、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；

三、被告人金某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；

四、被告人杜某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；

五、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；

六、责令被告人钱某某、杨某某、金某某、杜某某、李某共同退赔投资人经济损失；

七、在案扣押的被告人钱某某退赔款人民币460万元、被告人杨某某退赔款人民币252万元、被告人金某某退赔款人民币85万元并人退赔项执行，未随案移送的扣押款物由扣押机关依法处理。

北京市东城区人民检察院提出抗诉，钱某某、杨某某、金某某、杜某某提

出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：上诉人钱某某、杨某某、金某某、杜某某、原审被告李某某违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于钱某某、杨某某、金某某、杜某某、李某某均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚、积极退赔赃款，且杜某某有自首情节，依法可对钱某某、杨某某、金某某、李某某从宽处罚，对杜某某减轻处罚。原判定罪正确，审判程序合法，但对钱某某、杨某某、金某某、李某某判处罚金均低于1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，属于适用法律错误，依法应予改判。据此，判决如下：

一、维持北京市东城区人民法院(2022)京0101刑初1号刑事判决主文第四项、第六项；

二、撤销北京市东城区人民法院(2022)京0101刑初1号刑事判决主文第一项、第二项、第三项、第五项、第七项；

三、上诉人钱某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币12万元；

四、上诉人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；

五、上诉人金某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；

六、原审被告李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；

七、在案扣押的被告人钱某某退赔款人民币460万元、被告人杨某某退赔款人民币252万元、被告人金某某退赔款人民币85万元并入退赔项、罚金项执行，未随案移送的扣押款物并入罚金项执行，余款由扣押机关依法处理。

【法官后语】

本案非法吸收公众存款的犯罪事实均发生在2021年3月1日《中华人民共

和刑法修正案(十一)》施行之前,应适用1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款关于罚金刑的规定。

本案的争议焦点为,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行之前实施的非法吸收公众存款犯罪,法院在2022年3月以后作出裁判的,是否需适用2022年2月修改的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2022年非法集资解释》)第九条关于罚金刑的规定。一审对杜某某判处有期徒刑二年六个月,并处罚金3万元,其罚金刑符合1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定,但不符合《2022年非法集资解释》第九条的规定,对其罚金刑适用是否适当。

1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。《2022年非法集资解释》第九条规定,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处5万元以上100万元以下罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》,对于司法解释实施前发生的行为,行为时没有相关司法解释,司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件,依照司法解释的规定办理;对于新的司法解释实施前发生的行为,行为时已有相关司法解释,依照行为时的司法解释办理,但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的,适用新的司法解释。

本案非法吸收公众存款犯罪行为发生于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行之前。2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》没有规定非法吸收公众存款罪的罚金刑适用标准。本案原则上应适用1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条和《2022年非法集资解释》的相关规定,但是在罚金刑的司法适用上,《2022年非法集资解释》第九条与1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条关于限额罚金制的规定相比,大幅提升了罚金刑数额标准,属于不利于被告人的规定。根据《中华人民共和国刑法》从旧兼从轻原则及《最高人民法院、最高人民检察院关于适

用刑事司法解释时间效力问题的规定》的精神，对于在2021年3月《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行之前实施的非法吸收公众存款犯罪，法院应当直接依据1997年《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的罚金刑档次进行处罚，不需要适用《2022年非法集资解释》第九条关于罚金刑的规定。

编写人：北京市第二中级人民法院 丛卓义 邵泓斐

私募基金型非法集资犯罪的认定

——徐某某非法吸收公众存款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2022)鲁01刑终379号刑事裁定书

2. 案由：非法吸收公众存款罪

【基本案情】

2010年1月25日，张某某注册成立投资公司，后变更为投资集团。自2015年以来，投资集团以发行私募基金的名义，通过召开沙龙会议或口口相传等方式，承诺高额收益，违规发行私募基金产品募集资金，伪造盈利数据，虚构盈利假象，向社会不特定公众非法吸收资金。在资金兑付出现困难后，继续向社会公众募集资金，用于补偿前期产品的资金缺口。

被告人徐某某于2015年6月到投资集团任职。其间，违反私募基金相关法律法规规定，以口口相传等方式，向社会不特定公众公开宣传投资集团的私募基金产品。经审计，徐某某在职期间推介客户42人，相应非法吸收公众存款为 531340000元，其中23人损失303808396.86元。徐某某任营业部主管(团队

长)期间,所管理的客户经理推介客户91人,在徐某某任职期间非法吸收公众存款为882000000元,其中66人损失638445578.73元。

徐某某在职期间自投资集团领取佣金17069100元。

综上,徐某某非法吸收公众存款数额共计1413340000元。

【案件焦点】

1. 如何界定一般私募违法行为与虚假私募; 2. 虚假私募构成非法集资的认定。

【法院裁判要旨】

山东省济南市历下区人民法院经审理认为:被告人徐某某违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定,以非法吸收公众存款罪,判处徐某某有期徒刑六年,并处罚金15万元;追缴徐某某非法所得1706.91万元,按比例发还集资参与人。

一审宣判后,被告人徐某某提出上诉,主要上诉理由为,其认为投资集团是正规的私募基金,其只是在推介私募基金过程中出现违规行为,不应对其进行刑事处罚;其未公开宣传,未承诺还本付息或给付回报,其行为不属于非法吸收公众存款。

山东省济南市中级人民法院经审理认为: 一审判决定罪准确,量刑适当,审判程序合法,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定,裁定:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

本案的重点是对私募基金是否构成非法集资的审查。募集资金是否属于非法集资应严格依据非法集资的“非法性、公开性、利诱性、公众性”进行把关。但因私募基金这一金融方式的独特性,其“四性”把握具有相应特征。

私募基金型非法集资“非法性”的认定应着重把握借用合法经营的形式吸收资金这一判断标准。我国私募基金采用登记备案制，因登记备案相较于行政审批更为容易，未申请登记的基金管理人较为罕见，以形式判断标准即未经有关部门依法批准来认定非法性欠缺现实土壤，此时应审查其行为是否属于借用合法经营形式吸收资金，从具体行为本质进行非法性实质判断，即如果突破了私募基金私募性特征或对象特定性特征等，即从本质上否定私募基金性质，直接认定为借用合法经营形式吸收资金。当然，如果未依法登记而自行以私募基金的名义募集资金，直接以形式判断标准认定其具有非法性。

私募基金型非法集资“公开性”的认定应把握宣传方式是否系主动公开宣传，这里既包括为通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会宣传、口口相传等传统的非法集资宣传模式，还应注意私募基金本身的特殊性。《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定只能向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金，然而，实践操作中部分私募机构采用问卷调查等方式对投资者进行风险评估，之后规避合格投资者的法律要求，对不达标的客户以合户、代持等方式变通募资，这种情况下，其销售选择、能力评估的行为就背离评估本义，变异为公开宣传，足以认定该募资行为具有公开性。

私募基金型非法集资“利诱性”的认定应着重把握是否存在还本付息、给付回报的承诺及其他变相承诺。私募基金本身属于一种自由选择、盈亏自负的投资方式，《私募投资基金监督管理暂行办法》明确规定私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，并应制作风险揭示书告知风险。本案中，部分私募基金机构宣称其告知投资后果自负并签署风险告知书等，但又存在鼓吹盈利能力、告知“稳赚不赔、从未亏损、历年收益率非常高”，出具历史收益表等明示或暗示情形的，其实质仍是变相承诺不会亏损，保本付息，足以认定该募资行为具有利诱性。

私募基金型非法集资“公众性”的认定应把握是否违背私募基金合格投资者这一核心要求。私募基金的本质是以特定目标群体募集资金，与非法集资天然相斥，《私募投资基金监督管理暂行办法》以资产数额、年均收入、特定身

份等方面对私募基金合格投资者作出强制规定，突破上述规定就背离了私募基金的本质特征，架空私募的特定条件，进而转化为向不特定公众募集资金。私募基金型非法集资案件中，行为人以合户、代持等方式变通募资，任意扩大私募范围等方式，使得募资对象由特定目标群体变为不特定公众，这种情况应认定具有公众性。

本案中，在非法性方面，相关基金产品在登记、管理、记账，使用、投资者审查等多方面均存在大量不合规情况，属于借用合法经营的形式吸收资金，足以认定具有非法性；在公开性方面，投资集团以召开会议或口口相传等方式进行宣传，徐某某主动联系、鼓动投资、放纵口口相传，且将筛选合格投资者的行为架空、异化为对私募基金的宣传，具有公开性；在利诱性方面，投资集团和徐某某鼓吹投资集团盈利能力强，出具历史收益表，明示或暗示客户“稳赚不赔”，具有利诱性；在公众性方面，对达不到投资门槛的客户，徐某某以合户、代持的方式进行“拼单投资”，将私募转化为向不特定公众募资。综上，法院认定是以私募基金之名行非法集资之实，结合其没有非法占有目的，最终认定徐某某的行为构成非法吸收公众存款罪。

编写人：山东省济南市中级人民法院 李广大

利用未兑现利好型内幕信息获利的违法所得的认定及量刑考量

—— 李某某、王某某内幕交易案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2022)京03刑初63号刑事判决书

2. 案由：内幕交易罪

【基本案情】

2015年7月至8月，被告人李某某、王某某分别伙同A公司法定代表人赵某某(已死亡)，在A公司以拟支付现金方式购买B公司100%股权信息公开披露前，交易A公司股票。其中，被告人李某某操作其借用的他人证券账户买入A公司股票1801073股，成交金额共计人民币2454万余元，获利人民币890余万元。被告人王某某操作其本人以及他人证券账户买入A公司股票102.5万股，成交金额共计人民币1335万余元，获利人民币209万余元。经相关监管机关认定，A公司公告的上述重大资产重组事项属于《中华人民共和国证券法》规定的内幕信息，内幕信息敏感期为2015年6月30日至2015年12月15日，赵某某为内幕信息知情人。被告人王某某、李某某经民警电话通知，分别于2021年10月20日、10月21日到案。被告人李某某退缴违法所得人民币897.184769万元，被告人王某某退缴违法所得人民币209万元。

【案件焦点】

利用利好型内幕信息提前买入股票，但利好信息未兑现，信息公布后一段时间全部抛售并实际获利的，违法所得如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市第三中级人民法院经审理认为：被告人李某某、王某某分别伙同他人，在涉及对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用该内幕信息进行证券交易，二被告人的行为均已构成内幕交易罪，情节特别严重，依法均应予惩处。鉴于被告人李某某、王某某在与他人共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，违法所得已全部退缴在案，法院依法对二人减轻处罚并适用缓刑。被告人李某某、王某某在行政处罚阶段已退缴部分违法所得，并缴纳罚款，在量刑时可对其二人酌予从轻处罚，已缴纳的罚款可折抵罚金。对于被告人李某某、王某某的辩护人所提从宽处罚及适用缓刑的相关辩护意见，法院酌予采纳。违法所得是指通过内幕交易行为所获得的利益或者避免的损失。本案中，被告人李某某、王某某利用利好内幕信息

集中提前买入A公司股票，虽然利好信息未兑现，但卖出A公司股票时间距离复牌公告时间较短，卖出A公司股票获利与此前买入的违法行为具有因果关系，应当将二被告人卖出A公司股票实际获利金额认定为违法所得。故，对上述辩护意见，法院不予采纳。据此，判决如下：

一、被告人李某某犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币1000万元；

二、被告人王某某犯内幕交易罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币300万元；

三、被告人李某某退缴在案的违法所得人民币8304241.33元，依法没收，上缴国库。退缴在案剩余人民币667606.36元，用于执行本判决主文第一项财产刑；

四、被告人王某某退缴在案的违法所得人民币1486315.07元，依法没收，上缴国库。退缴在案剩余人民币603684.93元，用于执行本判决主文第二项财产刑。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

违法所得是内幕交易案件中需要查明的重要事实。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违法所得是指通过内幕交易行为所获利益或者避免的损失，但并未对违法所得的认定确立一个总的原则。《中华人民共和国刑法》关于泄露内幕信息、内幕交易罪对罚金的规定是以违法所得为计算基础的，即并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。因此，如何计算违法所得，对内幕交易立案追诉标准、“情节特别严重”的判断以及罚金刑的适用，至关重要。实务中，违法所得的认定常常成为争议焦点与审理难点。

根据内幕信息对内幕交易的影响，可以将内幕信息分为利好型内幕信息和利空型内幕信息。以股票买卖为例，内幕信息知情人员进行内幕交易，其必然是在掌握利好信息时买入股票以谋取股票上涨的利益，也必然是在掌握利空信

息时卖出股票以避免股票下跌的损失。①对利好型内幕信息在复牌后兑现的，因复牌后的获利均与利用内幕交易存在因果关系，故不论在复牌日还是复牌日之后抛售股票，均应以抛售后的实际获利认定为内幕交易的违法所得。实践中，违法所得的计算，应以内幕交易行为终止日、内幕信息公开日、行政调查终结日或其他适当时点为基准日期。但当利好型内幕信息因重组失败等原因而未兑现，如何认定内幕交易的违法所得，确定违法所得计算的基准日期，素有较多争议。笔者认为应当坚持实际获利标准，内幕信息对市场的影响是复杂的，是否存在内幕信息影响力耗尽、其他市场介入因素通常难以判断，内幕交易造成的违法后果难以被简单剥离，不能仅因利好信息未兑现就认定因果关系中断；且行为人在利好消息未兑现的情况下选择继续持有股票，并不能排除其是为避免立即抛售股票获利可能面临处罚的情况，也不能就此认定行为人仅因市场供求因素和个人投资决策选择继续持有的想法。

本案即符合利用未兑现利好型内幕信息获利的情形。被告人李某某、王某某分别于2015年8月4日至17日、2015年7月1日至8月28日即内幕信息敏感期内买入A公司股票，8月29日A公司公告停牌，12月15日A公司公告重组消息，后重组失败，A公司股票于2016年1月5日复牌。被告人李某某、王某某分别于2016年3月8日至4月25日、2016年3月3日卖出持有的A公司股票，此时分别盈利898万余元、209万余元。对于违法所得的计算，控辩双方争议较大。公诉机关以被告人卖出股票实际获利计算违法所得，辩护人则认为，A公司于2015年8月29日公告资产重组进行停牌，于2016年1月5日复牌，其间发布终止重组的公告，因为重组终止故并未对市场产生直接影响，应按照复盘日的收盘价计算违法所得，按照该价格计算，本案不存在违法所得。笔者认为，二被告人利用利好型内幕信息集中买入A公司股票，该行为已是违法行为，后卖出时间距离复牌公告仅两三个月，时间较短，二被告人的违法行为已经对证券市场产生了一定影响，此期间持有的增值不能归属于不法分子，

①罗开卷：《利好型内幕信息复牌后未兑现的违法所得认定》，载《人民司法》2014年 第8期。

应属于自然增值，且在此短时间内并无证据显示有其他市场介入因素，故应将二被告人实际卖出股票获利金额认定为违法所得数额。

编写人：北京市第三中级人民法院 方玉
李若柳

37

内幕信息形成时间以相关事实何时 具备很大实现可能性为实质认定标准

—— 顾某内幕交易案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2021)沪01刑初95号刑事判决书

2. 案由：内幕交易罪

【基本案情】

2016年下半年，某基金对外物色持有信托牌照的收购对象，并接触多家信托公司，但均未谈判成功。2016年12月，被告人顾某向某基金董事长韩某提议收购某集团股权事宜。之后，韩某、顾某与某1集团实际控制人钱某、某公司董事长闵某等人，针对合作收购某集团事宜多次商谈，并决定由某基金、某1集团及顾某共同增资顾某担任法定代表人的某企业，并通过某企业收购某集团的具体方案。2017年1月下旬至4月中旬，某企业与其一致行动人某基金国际分别通过集中竞价系统购入某集团股票，持有某集团5%股份。同年4月16日，某

集团发布公告《某企业及其一致行动人某基金国际增持计划》，并于次日停牌，直至同年8月2日复牌。在上述内幕信息敏感期内，顾某于2016年12月28日至2017年2月13日，多次联系其朋友魏某代为操作顾某本人名下证券

账户，并使用顾某自有资金买入某集团股票共计77.2万余股，交易金额977.7万余元，非法获利31.6万余元。

【案件焦点】

如何认定内幕信息的形成时间。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：

1. 应将被告人顾某提议某基金收购某集团股权的初始时间作为内幕信息形成时间。在案证据证明，顾某得知某基金对外物色持有信托牌照的收购对象时，即建议某基金收购持有信托等多块金融牌照的某集团，顾某作为影响内幕信息形成的动议、筹划人员，其动议、筹划的初始时间，应当认定为内幕信息的形成时间。

2. 被告人顾某提议某基金收购某集团股权的初始时间不晚于2016年12月。理由是：（1）证人钱某某、董某某、韩某、闵某等人的证言证明，顾某系在2016年12月初某次饭局上向韩某提议通过收购某集团股权的方式获取信托牌照。2016年12月至2017年1月，前述人员多次就收购方案、计划进行商讨。

（2）证人韩某、董某某等人称与顾某参加第一次饭局的时间为2016年11月中旬，之后不久又与顾某参加了第二次饭局，顾某在第二次饭局上明确提出了收购某集团股权的建议。

3. 监管机关认定的内幕信息形成时间不晚于2017年1月18日并非动议时间，而是筹划、决策时间。经查，2017年1月15日，某基金国际就收购某集团进行立项；同年1月19日，某基金投资团队提交审议收购某集团股权的可行性报告。显然，前述时间不可能是动议的时间。

被告人顾某作为内幕信息知情人员，在对证券交易价格有影响的重大信息尚未公开前，买入、卖出该证券，情节严重，其行为已构成内幕交易罪。上海市第一中级人民法院综合考虑顾某具有立功、退赔等情节，故对其以内幕交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币158万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、内幕信息形成时间认定的一般判断规则

内幕交易是“抢跑行为”，有效的信息传递和公平的信息竞争是证券市场健康发展的基础，内幕交易犯罪的实质危害在于行为人利用其可以提前获悉内幕信息的信息优势从事证券交易，滥用了应及时向市场所有参与者披露信息经济价值，严重破坏证券市场交易秩序，损害其他投资者的利益。据此，行为人既然是利用信息优势，则其从事证券交易行为所基于的信息应当具有较高程度的确定性，也就是说，内幕信息形成时间应是相关事实具备很大实现可能性之时。

“具备很大实现可能性”标准可以平衡保护法益的根本目的和刑法谦抑的基本理念，若将相关事实确定发生作为内幕信息形成时间，则在相关事实筹划发展过程中根据掌握信息线索内心确信事实确定发生的人员就难以纳入打击范围，不利于保护法益；若将相关事实仅有可能发生视为内幕信息形成，则可能会有一些利用高度不确定信息进行交易的高风险行为被纳入打击范围，有违刑法谦抑原则。在具体案件中适用该标准时，还要考虑到市场交易行为总是对信息提前反应，而且为了有效压缩内部交易时间、预防内幕交易犯罪发生，对于存在模糊地带的案件，应当坚持价值判断，采取从严认定思路，将内幕信息形成时间适度提前认定。

二、并购重组中内幕信息形成时间的具体判断规则

内幕信息类型复杂，涉及不同的商业行为，可以分类型讨论内幕信息形成时间认定的细化规则。并购重组领域是我国内幕交易犯罪案件的重灾区，依照上述“具有很大实现可能性”标准，可以将并购拟交易双方确定的时间认定为内幕信息形成时间，但是由于具体案件情况较为复杂，有必要根据汇报过程、审批情况等分别讨论。

一是对于“由下至上”汇报讨论型的并购重组案件，原则上以双方高层达成合作意向为内幕信息形成时间。“由下至上”是指先由具体负责人员考察走访了解情况，再将相关信息向管理层汇报，双方管理层由此见面接触并形成合

二、破坏社会主义市场经济秩序罪 155

作意向。这类案件中，由于具体情况已经进行调查分析，各方具体负责人员也会将相关情况向各自管理层汇报，一方提出管理层见面协商，另一方管理层表示同意，且双方在见面商谈后达成合作意向的，后续就是具体工作的落实，可以视为相关事实具有很大实现可能性。

二是对于“由上至下”落实部署型的并购重组案件，原则上以居于主动地位方高层开展客观可见的工作为内幕信息形成时间。“由上至下”是指公司高层先动议，后召集下属并就是否可行、如何实施等具体问题进行讨论。这类案件中，由于公司高层具有决定权，故其决议实施的事项具有实现的较大可能性，但是要达到很大可能性，还需要相关事项具备客观上的可操作性。需要说明的是，以上仅适用于居于主动地位一方，若并购重组需要对方同意才可以实施的，则仍需要双方高层达成合作意向。

三是对于需经监管部门审批才能开展的并购重组案件，原则上以审批通过作为内幕信息形成时间。对于某些国有公司开展并购重组事宜，需要经主管部门批准方可实施，则在主管部门批准之前，并购重组能否开展存在高度不确定性，故应以主管部门同意或者向主管部门汇报作为内幕信息形成时间。

本案就属于由上至下落实部署型的并购重组案件，某基金决议对外物色持有信托牌照的收购对象。2016年12月上旬，被告人顾某作为某基金子公司的股东及法定代表人，向某基金董事长韩某提议收购某集团股权以获取某集团信托牌照，韩某表示同意，且现有证据证明韩某与顾某、钱某某等人亦于2016年12月上旬商讨具体收购方案。据此，韩某作为收购方董事长因顾某提议而决定收购某集团，并召集下属商讨具体收购方案，并且收购方式为集中竞价，其居于主动地位，故应当以韩某同意顾某提议并商讨收购方案作为内幕信息形成时间。

编写人：上海市第一中级人民法院 李长坤
张金玉

场外配资行为及配资人员自行交易的刑法规制与责任承担

—— 黄某、王某等操纵证券市场案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市高级人民法院(2023)沪刑终55号刑事裁定书

2. 案由：操纵证券市场罪

【基本案情】

2020年5月起，被告人黄某指使其操盘团队人员被告人黄某1、王某某、周某某、姜某等人集中资金优势，使用施某、严某(均另案处理)、被告人王某等人提供的证券账户连续交易“某科技”股票，至2020年8月31日，形成持股优势。2020年10月，黄某为继续操纵“某科技”股票，又从李某、林某(均另案处理)等人处获取资金及相关证券账户，用于该股票的证券交易。2021年1月，在“某科技”股票价格下跌的情况下，黄某通过李某、林某联系相关金融机构人员买入并锁定流通股份，当月机构方陆续买入“某科技”股票。2021年3月10日，黄某操盘团队及机构方大量卖出“某科技”股票，当日上述证券账户持有“某科技”流通股份数量占该证券实际流通股份总量的比例从逾11%大幅下降至约4%，至2021年6月30日降至约1%。

在上述操纵过程中，黄某在操盘团队内全面负责决策、指挥操盘交易，同时寻找配资方，安排保证金、补仓款等资金划转事宜，还通过中间人联系金融机构买入“某科技”股票；王某通过“A”分仓软件向黄某提供与54个个人证券账户关联的分仓账户及配资资金，并约定参与部分分仓账户交易的利润分成，

为黄某从李某、林某处获取资金提供担保，代为向相关金融机构人员支付“好处费”等；黄某1、王某某、周某某、姜某根据黄某的指令下单交易证券、对接配资账户风控事宜、操盘团队的财务、后勤事宜等。

经审计，2020年8月31日至9月11日连续10个交易日及2020年11月4日至2021年3月9日连续84个交易日，黄某操盘团队控制的证券账户持有“某科技”流通股份数量达到该证券实际流通股份总量的10%以上，任意连续10个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量20%以上，其中2020年12月25日至2021年2月18日任意连续10个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量的50%以上。2020年8月31日至9月11日，涉案账户交易获利103万余元；2020年11月4日至2021年3月9日，涉案账户交易亏损1753万余元；共计亏损1650万余元。

【案件焦点】

1. 王某明知黄某等人操纵股票，作为配资方之一向黄某提供绑定个人证券账户的分仓账户及配资，应如何确定其罪名及情节；2. 王某在黄某等人操纵期间利用分仓账户绑定的个人账户自行交易同一股票，其自行交易的部分是否应计入全案操纵的交易量，黄某、王某等人对此如何承担责任。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：被告人黄某伙同被告人黄某1、王某某、姜某、周某某等人组建操盘团队，通过被告人王某等人获取大量配资及证券账户，集中资金优势、持股优势连续买卖或者联合买卖“某科技”股票，

操纵证券市场，影响该证券的交易价格和交易量，情节特别严重，其行为均已构成操纵证券市场罪，且系共同犯罪。其中，王某明知黄某等人操纵证券市场，提供配资并参与拉取配资等，具有操纵证券市场的共同故意，且对黄某等人的操纵情节可能达到情节特别严重具有概括的认识，王某应对黄某等人操纵的全案情节承担共犯责任；黄某希望或放任王某自行购买同一股票以抬升股价，未对王某提供的证券账户内交易量异常质疑，黄某对王某自行交易的情况应具有

概括的认知，故王某自行交易的部分应计入共同犯罪的交易量，王某与黄某等对此应共同承担责任。据此，依法判决：

一、被告人黄某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100万元；连同前罪犯逃汇罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100万元；

二、被告人王某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100万元；

三、被告人黄某1犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20万元；

四、被告人王某某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10万元；连同前罪犯逃汇罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10万元；

五、被告人姜某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10万元；

六、被告人周某某犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元；

七、违法所得予以追缴，犯罪工具予以没收。

一审判决后，王某提出上诉，称其系从犯，原判量刑过重。

上海市高级人民法院经审理认为：原判的意见正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、明知他人操纵证券市场仍然为其配资，具有操纵证券市场的共同故意，通常以操纵证券市场罪共犯论处；对全案操纵情节有概括认知的，提供部分配资亦对全案交易情节承担共犯责任

（一）明知他人操纵证券市场仍然为其配资，通常以操纵证券市场罪共犯论处
场外配资是指通过所谓的借款协议等，约定将自有资金出借给融资方用于

交易股票，在资产市值达到平仓线后强行卖出股票以偿还本息的行为。按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，场外配资行为属于融资融券业务，而融资融券属于国家特许经营的金融业务，需要经过监管部门批准并获得业务许可，未经依法批准，任何单位和个人非法从事配资业务均具有行政违法性。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重的，应以非法经营罪论处。同时，按照刑法共同犯罪的一般理论，配资人员明知他人操纵证券市场仍然为其配资，其主观上具有操纵证券市场的共同故意，客观上实施了积极提供配资帮助的行为，成立操纵证券市场的共犯。据此，场外配资行为的刑法规制中，可能构成非法经营罪，也可能构成操纵证券市场罪的共犯，同时构成两罪时，根据想象竞合犯的处理规则，择一重罪处理，轻重程度相当则可结合全面评价配资人员的犯罪事实、性质、参与程度、社会危害程度等做出判断。

本案被告人王某向黄某提供配资的方式是将与个人账户随机绑定的虚拟分仓账户交由黄某团队使用，分仓账户中仅能交易“某科技”这一只特定的股票，且王某多次前往黄某操盘交易室，知晓黄某团队使用多个手机下单，故对于黄某团队以规避监管的手法交易“某科技”股票应系明知；王某自2020年9月起与黄某用电话或语音方式进行风控对接规避监管，收到配资账户交易警示函后明知违法仍然继续提供配资。综上，王某明知黄某团队操纵证券市场，仍向黄某提供或促成大量配资，以拉抬股价牟取利益，还与黄某约定了部分配资账户的利益分成，其主观上具有操纵证券市场的共同故意，客观上实施了积极提供帮助的行为，依法应以操纵证券市场罪的共犯论处。

（二）对全案操纵情节有概括认知的，提供部分配资对全案交易情节承担共犯责任

在操纵证券犯罪中，操纵团伙的资金通常来自多个、多层资金方，可能包括配资公司、大配资中介、小配资中介以及民间个人资金提供方，上述资金共同组成操纵资金，得以形成资金优势、持仓优势，实现连续交易等操纵证券市场行为。具言之，客观上，无论是何一层级的配资方，其提供的配资资金均是

